

1501379-71.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... características de um homem que estava no tráfico. Abordaram o réu, cujas características coincidiam. Em poder do réu havia dinheiro (moedas e notas trocadas), confessou o tráfico e mostrou que guardava as drogas embaixo de um cone, onde as apreenderam. As drogas estavam divididas em porções. O cone ficava do outro lado da rua. Não conhecia o réu anteriormente.

No mesmo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, . - Vila Conceição

CEP: 09912-010 - Diadema - SP

Telefone: (11) 4056-6600 - E-mail: diadema3cr@tjsp.jus.br

1501379-71.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501379-71.2022.8.26.0537 Controle nº 1009/2022

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NILMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

NILMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 29 de junho de 2022, por volta das 05:30 horas, na Rua Raul Seixas, altura do número 84, Bairro Casa Grande, adquiriu, tinha em depósito e guardava, para consumo de terceiros, maconha, cocaína e "crack", drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia (fls. 44/48).

Foi apresentada defesa prévia (fls. 82/83), sendo recebida a denúncia em 06.09.22 (fls. 86/87). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. O réu foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dr.ª Promotora de Justiça requereu a procedência da ação por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com aumento da pena pela quantidade de drogas, antecedentes e agravante da reincidência específica, que seja afastada a aplicação do art. 33, § 4.º por ser reincidente, fixação de regime fechado e perdimento do dinheiro.

O Defensor Público requereu a absolvição por insuficiência de provas ou em caso de eventual condenação, a fixação de regime semiaberto diante da detração penal.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fls. 08), o acusado permaneceu calado.

Em juízo, negou ter praticado o crime. Narrou que se desloca de Serraria até o bairro Cazuza por fazer entregas terceirizadas da Yoki. As moedas recebia de "caixinhas" que ganha no seu trabalho. Narrou que se encontrava no local para trocar as moedas no ferro velho. Informou que conversando com dois rapazes, um deles era o filho do dono do ferro velho. Aguardava o dono do ferro velho chegar para trocar as moedas. Tem condenação por dois tráficos (2006 e 2011). Não indicou para os policiais onde estavam as drogas. O policial o levou até o outro lado da rua e inclusive lhe deu uma coronhada, sendo que ficou machucado na cabeça. Não conhecia os policiais anteriormente.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 06/07), disseram que o local é conhecido ponto de tráfico, receberam uma denúncia anônima, que dava conta de que um homem trajando blusa vermelha e calça jeans estava lá vendendo drogas. Relataram que o réu apresentava as mesmas características informadas na denúncia. Narraram que em revista pessoal localizaram na posse do réu a quantia de R\$ 204,26, em moedas e notas diversas. Falaram que o réu confessou o tráfico e informou que guardava as drogas em uma mini bolsa, escondida dentro de um cone que estava na calçada da frente. Foram até o local indicado pelo réu, onde encontraram a bolsa e no interior desta havia 22 invólucros de maconha, 35 papelotes de cocaína e 49 pedras de "crack", todos embalados e individualizados.

João Batista (policial), em juízo, afirmou que um popular passou as características de um homem que estava no tráfico. Abordaram o réu, cujas características coincidiam. Em poder do réu havia dinheiro (moedas e notas trocadas), confessou o tráfico e mostrou que guardava as drogas embaixo de um cone, onde as apreenderam. As drogas estavam divididas em porções. O cone ficava do outro lado da rua. Não conhecia o réu anteriormente.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Alexandre. Esclareceu, ainda, que o réu estava parado na calçada conversando com mais dois rapazes. Nada de ilícito havia com as outras pessoas. Foi conduzido o réu, porque as características coincidirem, bem como apreenderam dinheiro, confessou e indicou onde estavam as drogas (embaixo de um cone), onde foram apreendidas. Não conhecia o réu.

O fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA - Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º

1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24).

O réu disse que não conhecia os policiais, pelo que não teriam motivos para incriminá-lo indevidamente.

A quantidade de drogas apreendidas (fls. 12 - 35 papelotes de cocaína, 49 pedras de "crack" e 22 invólucros de maconha), aliados à falta de comprovação de ocupação lícita, o que é incompatível com a condição de usuário e, ainda, considerando que estava dividida em invólucros, e que foi apreendido dinheiro, não sendo demonstrada sua procedência, bem como a confissão informal e os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa quantidade e variedade se não fosse traficante.

Irrelevante que não tenham sido presenciados atos de mercancia, posto que denunciado pelas condutas de adquirir, ter em depósito e guardar.

A versão do réu de que trabalha, o dinheiro apreendido era das "caixinhas" por trabalhar como entregador, bem que estava no local para trocar as moedas no ferro velho está isolada nos autos, posto que alegou, mas nada provou como lhe incumbia

nos termos do art. 156 do CPP. Ademais, já ostenta condenações por tráfico (antecedentes e reincidência) e não provou ter ocupação lícita, o que torna ainda mais frágil a sua negativa.

Apesar das ponderações da defesa, os policiais foram uníssonos no sentido de que apreenderam dinheiro com o réu, que confessou o tráfico e apontou um cone, dentro do qual localizaram as drogas.

Portanto, não é caso de absolvição como requerido pela defesa.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

A alegação do réu de que foi agredido fica afastada pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 73), o qual não constatou lesões.

Desta forma, impõe-se a condenação do acusado, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 15/17) e laudo definitivo (fls. 69/71).

Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos possui antecedentes (fls. 39 - proc. 5095-09.2006 - pena julgada extinta em 20.09.10 - fls. 34; fls. 40/41 - proc. 14591-33.2004 - pena privativa de liberdade cumprida ou julgada extinta em 26.05.11) e é reincidente (fls. 39/40 - proc. 12296-76.2011 - pena julgada extinta em 13.05.20).

O art. 5.º inc. XLVI da Constituição Federal prevê que "a lei regulará a individualização da pena" e o art. 61, inc. I, do Código Penal determina que a reincidência é circunstância agravante da pena.

Conforme R.E. 723.211, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 25.06.13:

"O Plenário desta Corte, no julgamento do RE453.000/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, no dia 4/4/2013, em regime de repercussão geral, julgou o mérito do tema 114 e negou provimento ao RE que alegava a inconstitucionalidade do agravamento da pena em virtude da reincidência, consolidando o entendimento de que não configura bis in idem.

Desse modo declarou ser constitucional a aplicação do instituto da reincidência como agravante da pena em processos criminais (art. 61, I, do Código Penal)".

Assim, a reincidência será considerada como circunstância agravante.

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, especialmente que possui antecedentes, bem como em razão da quantidade média de drogas (fls. 12 - 35 papérolas de cocaína, 49 pedras de "crack" e 22 invólucros de maconha), já que pequena quantidade nesta Comarca é inferior a 100 invólucros e enorme de quilos, fixo a pena-base para o tráfico em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, à razão mínima por inexistirem elementos quanto à real situação econômica do acusado.

Aumento a pena de 1/6 pela reincidência.

O réu não faz jus à redução do art. 33, § 4.º, porque é reincidente e, portanto, não preenche um dos requisitos legais (não é primário) que são cumulativos, além de se dedicar a atividades criminosas, já que ostenta condenações anteriores também por tráfico.

Não se trata de tráfico privilegiado, pelo que não incide no caso em tela o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, pois conforme prevê o art. 33, § 2.º, "b" e "c" só se aplicam regimes mais brandos ao "condenado não reincidente". As circunstâncias não são favoráveis, pois é reincidente específico (fls. 39/40 - proc. 12296-76.2011 - pena julgada extinta em 13.05.20), além de possuir antecedentes específicos (fls. 39 - proc. 5095-09.2006 - pena julgada extinta em 20.09.10 - fls. 34) e por furto qualificado (fls. 40/41 - proc. 14591-33.2004 - pena privativa de liberdade cumprida ou julgada extinta em 26.05.11), o que denota personalidade voltada para crimes, uma vez que sequer provou possuir ocupação lícita, o que demonstra que o tráfico é seu meio de vida e, ainda, houve aumento da pena pela quantidade de drogas. Trata-se de crime de extrema gravidade,

uma vez que causa dependência física e psíquica atingindo inúmeros usuários, provocando perda de emprego, envolvimento em delitos para comprarem drogas, venda de bens inclusive de familiares para satisfação do vício, acarretando efeitos deletérios para a sociedade.

Inviável a conversão em restritiva de direitos ou "sursis", diante do montante da pena.

Inaplicável o disposto no art. 387, § 2.º, do CPP, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, já que a fixação da pena e regime estão previstos nos arts. 33 e 68, ambos do Código Penal (norma de direito material), sendo que a progressão de regime deve ser apreciada pelo juiz da execução de acordo com o art. 112 da LEP que é lei especial e prevalece sobre a geral, ou seja, "Lex specialis derogat generali" (Lei especial derroga a geral), não se justificando que o preso provisório possa obter tal benefício sem preencher os requisitos da LEP. Ademais, havendo recurso será expedida guia de recolhimento provisória, pelo que não haverá qualquer prejuízo, pois a progressão será apreciada pelo juízo competente. Além disso, sequer preenche o lapso temporal para tanto (preso em 29.06.22, pelo que ainda que considerado 2/5 só ocorreria em 31.08.25).

Por outro lado, "ad argumentandum", ainda que se considere a detração conforme entendimento do STJ, o fato é que o regime não está atrelado apenas à pena, mas também às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, pelo que diante dos antecedentes e reincidência, inclusive específica (circunstância judicial agravante), não é recomendável outro regime diverso do acima fixado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO NILMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO à pena de 7 (SETE) ANOS, 11 (ONZE) MESES e 8 (OITO) DIAS DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME FECHADO e 793 (SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Tendo em vista que o réu foi preso em flagrante por crime equiparado aos hediondos previsto na Lei n.º 8072/90, que o M.P não concordou com o recurso em liberdade, bem como por estarem presentes os requisitos da preventiva, sendo crime de extrema gravidade, fazendo-se necessária a prisão para garantia da ordem pública para evitar a prática de novos crimes de gravidade e para assegurar a aplicação da lei penal, posto que não há nada que o vincule ao distrito da culpa (não comprovou ocupação lícita nem residência fixa) e é incabível qualquer benefício, recomende-se na prisão em que se encontra.

Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Considerando que o dinheiro apreendido (fls. 12 e 62 - R\$ 204,26), conforme prova produzida é proveito do tráfico, determino o perdimento em favor da União, providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (art. 63 da Lei n.º 11343/06).

Em relação à bolsa tipo "nécessaire" apreendida (fls. 12) e já periciada (fls. 97/99), tendo em vista que não possui valor econômico, oficie-se desde já informando que não interessa mais aos autos podendo ser eliminada.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 50) e providencie-se o necessário para transferência do dinheiro ao FUNAD, comunicando-se à SENAD (art. 63, §4.º, da Lei n.º 11343/06) e efetue-se o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 29 de setembro de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA